Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Canoas

Rua Lenine Nequete, 60 - Bairro: Centro - CEP: 92310205 - Fone: (51) 3472-1184 - Email: frcanoas2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5024915-76.2022.8.21.0008/RS

AUTOR: SARA STEINMETZ MOREIRA DE AZEVEDO

RÉU: BRADESCO SAUDE S/A

SENTENÇA

Sara Steinmetz Moreira de Azevedo ajuizou a presente **Ação de Obrigação de Fazer** contra **Bradesco Saúde S/A**, partes já qualificadas. Alegou, em resumo, que é beneficiária do plano de assistência à saúde, operado pela empresa ré. Disse que estava grávida de 11 semanas e que descobriu sofrer de trombofilia, doença que pode causar a interrupção da gestação, bem como risco de morte à parturiente. Salientou que, em razão da grave patologia, deve ser-lhe ministrada a solução injetável denominada ENOXOPARINA 40mg, durante todo período gestacional. Asseverou que a medicação possui custo elevado e que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento. Referiu que, devido à necessidade de aplicação diária do medicamento, contatou a demandada para que custeasse o seu tratamento, contudo, teve a cobertura do tratamento negada. Afirmou que, segundo a ré, somente teria direito à medicação, caso fosse diariamente ao hospital para realizar as aplicações, de segunda a sexta-feira, não havendo disponibilização nos finais de semana. Discorreu acerca da abusividade da negativa, tendo em vista que o medicamento possui registro na ANVISA, sendo que o Ministério da Saúde, através do CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia do SUS, realizou estudo técnico sobre o tratamento da trombofilia para gestantes, aprovando a incorporação da Enoxaparina Sódica imediatamente a descoberta da gestação. Apontou a existência da Medida Provisória nº 107, de 02/09/2021, que determina a inserção do medicamento no rol da ANS quando incorporado pela CONITEC. Sustentou que é abusiva a cláusula contratual que determina a exclusão do fornecimento de medicamentos pela operadora do plano de saúde tão somente pelo fato de serem ministrados em ambiente ambulatorial ou domiciliar. Requereu, em sede de tutela de urgência, a determinação para que a requerida arque com o tratamento de TROMBOFILIA, durante toda a gestação, através do fornecimento da medicação enoxoparina 40MG ou outra dosagem que vier a ser solicitada por indicação médica, tornando-a definitiva com a procedência da ação. Pediu a assistência judiciária gratuita. Juntou documentos.

Para análise do pedido de assistência judiciária gratuita, determinou-se a intimação da parte autora para que juntasse aos autos cópia de suas três últimas declarações de imposto de renda ou, ainda, documento que comprovasse a inexistência de tais declarações junto à base de dados da Receita Federal, nos termos do art. 99, §2º, parte final, do CPC. Ainda, foi deferida a tutela de urgência, para determinar que a demandada procedesse à disponibilização do medicamento necessário ao tratamento da requerente (enoxoparina 40MG, uma vez ao dia), pelo período que se mostrasse necessário durante a gestação da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, aplicável desde o descumprimento da medida e após a efetiva intimação da parte demandada, consolidada em 30 (trinta) dias (documento 1 do evento 4).

Em petição anexada no documento 1 do evento 15, a parte autora noticiou o descumprimento da tutela de urgência pela parte ré, postulando o bloqueio de valores, via Sisbajud, para aquisição do fármaco junto a rede privada, bem como a fixação de multa.

Em decisão lançada no documento 1 do evento 17, determinou-se a intimação da demandante para que juntasse aos autos 03 orçamentos do medicamento necessário ao seu tratamento. Ainda, quanto à multa diária pretendida, restou consignado que já houve a fixação de astreintes na decisão do evento 4, que poderá ser objeto de execução a ser movida pela requerente após o julgamento do mérito da ação.

Juntados os orçamentos, deu-se vista dos autos ao Ministério Público, que se absteve de atuar no presente feito (documento 1 do evento 26).

Citado, o requerido apresentou contestação (documento 1 do evento 28). Alegou, em suma, que não há que se falar em descumprimento da medida pois, tanto a segurada quanto o referenciado que a acompanhava foram cientificados da liberação do medicamento, nos exatos termos da decisão exarada. Disse que considerando a recomendação do artigo 35-C da Lei nº 9.656/1998, tendo sido apresentada a situação de gestação e trombofilia, após a recepção da NIP foi reconsiderado o fornecimento do CLEXANE® (ENOXAPARINA SÓDICA), para uso ambulatorial não domiciliar, mediante solicitação e apresentação de relatório médico e exames que justifiquem o uso da medicação. Referiu que tal autorização ocorreu de modo indevido, por mera liberalidade da seguradora, uma vez que a segurada apresenta exclusivamente mutação heterozigótica do gene MTHFR que foi excluído da recomendação no último documento da CONITEC. Asseverou que tal exclusão de cobertura é ratificada em cláusula constante nas Condições Gerais da Apólice contratada. Destacou que, diante disso, não há que se falar em obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para uso domiciliar, eis que expressamente excluído da contratação entabulada, que se deu em consonância com a Lei 9.656/98 e com o regulamentado pela ANS. Sustentou que o medicamento não está recomendado em bula para uso profilático em gestante com mutação heterozigótica exclusiva como é o caso da segurada. Apontou que é lícita a exclusão de cobertura contratual, consoante a Resolução Normativa nº465 da ANS, de tratamento "Off-Label", qual seja, aquele que, embora ministrado com medicamento liberado e reconhecido não tem indicação específica ao caso da paciente. Informou que consta nas Condições Gerais da Apólice, conforme Cláusula 5ª, exclusão contratual para medicamentos e eventos que não sejam de cobertura obrigatória pela ANS. Esclareceu que não pode ser compelida a cobrir tratamentos ou medicamentos que não constam no rol da ANS ou que não obedeçam a sua Diretriz de Utilização (DUT). Ressaltou que a Lei nº 9.656/98, que veio ampliar os direitos dos segurados, não prevê cobertura indiscriminada para o tipo de medicamento buscado pela parte demandante. Requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

A seguir, foi deferido o pedido de sequestro de valores, via Sisbajud, de valores suficientes para custear o tratamento da autora (documento 1 do evento 31).

Inconformada com a decisão que deferiu o pedido de tutela, a parte ré interpôs recurso de agravo de instrumento (evento 29), o qual foi provido pela Superior Instância, para o fim de suspender a decisão recorrida (evento 32).

Ante a decisão proferida pela Instância Superior, foi determinado o desbloqueio dos valores constritos via Sistema Sisbajud (documento 1 do evento 34).

Sobreveio réplica à contestação (documento 1 do evento 41).

Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, as partes nada requereram.

Após, determinou-se a suspensão do feito até o trânsito em julgado do agravo de instrumento, ante a concessão de efeito suspensivo (documento 1 do evento 51).

Em seguida, considerando que a prefacial de ausência de interesse de agir, em virtude da perda superveniente de objeto da demanda, poderia ser analisada por este Juízo, determinou-se a intimação da parte autora para que informasse se ainda persistia a necessidade de utilização da medicação em comento, comprovando documentalmente, haja vista o disposto no art. 10, do CPC (documento 1 do evento 74).

Em petição anexada no documento 1 do evento 77, a requerente informou que, no momento, não faz mais uso da medicação, eis que já ocorrido o nascimento de seu filho.

Da petição apresentada pela autora (documento 1 do evento 77), deu-se vista ao requerido, que postulou a improcedência da demanda.

Na sequência, determinou-se a intimação da parte autora para que juntasse aos autos cópia de suas 03 últimas declarações de imposto de renda ou, ainda, documento que comprove a inexistência de tais declarações junto à base de dados da Receita Federal (documento 1 do evento 82), o que foi atendido no evento 85.

Por fim, os autos vieram-me conclusos para sentença.

É O RELATÓRIO.

PASSO A DECIDIR.

É caso de julgamento do processo no estado em que se encontra, na forma do art. 355, I, do CPC, pois a questão é essencialmente de direito e os documentos trazidos ao feito são suficientes para esclarecer os fatos.

Trata-se de ação ordinária, na qual pretende a autora o fornecimento do medicamento ENOXOPARINA 40mg. Fundamentou sua pretensão, alegando que estava grávida de 11 semanas e sofria de trombofilia, doença que pode causar a interrupção da gestação, bem como risco de morte à parturiente.

A presente ação tramitou regularmente, sendo que, por fim, a demandante noticiou que não necessita mais fazer uso da medicação pleiteada na exordial, ante já ter ocorrido o nascimento do filho que esperava quando do ajuizamento da presente ação.

Inobstante a desnecessidade do tratamento acarrete a perda superveniente do interesse processual, considerando tratar-se de pedido único neste feito, tenho que se revela imprescindível o exame do mérito da lide para confirmação, ou não, da antecipação de tutela deferida, assim como para apurar a sucumbência das partes.

Observe-se que, este Juízo deferiu, em sede de tutela de urgência, a determinação pra que a demandada procedesse à disponibilização do medicamento necessário ao tratamento da requerente (enoxoparina 40MG, uma vez ao dia), pelo período que se mostrasse necessário durante a gestação da autora, sob pena de multa diária. Inconformada, a requerida interpôs agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento para o fim de suspender a decisão recorrida.

Desse modo, passo ao exame do mérito da lide.

Resta incontroversa a relação contratual estabelecida entre as partes, não havendo dúvidas de que a requerente é beneficiária do plano de saúde fornecido pelo demandado.

Assim, a matéria a ser enfrentada nestes autos cinge-se à apuração da existência de obrigatoriedade, da parte ré, em fornecer o medicamento postulado pela autora.

Os serviços securitários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo, dispondo aquele diploma legal em seu art. 3º, § 2º, o seguinte:

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° (...)

§ 2° - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

No caso dos autos, denota-se que é incontroverso o diagnóstico de Trombofilia e a prescrição médica para uso do medicamento Enoxaparina 40mg.

Compete à ANS, dentre outras atribuições, a elaboração do rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, decidiu:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO ACERCA DA TAXATIVIDADE OU NÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, INEQUIVOCAMENTE ESTABELECIDA NA SUA PRÓPRIA LEI DE CRIAÇÃO. ATO ESTATAL DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO AO QUAL SE SUBMETEM FORNECEDORES E CONSUMIDORES DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE DIREITO PRIVADO. GARANTE A PREVENÇÃO, O DIAGNÓSTICO, A RECUPERAÇÃO E A REABILITAÇÃO DE TODAS AS ENFERMIDADES. SOLUÇÃO CONCEBIDA E ESTABELECIDA PELO LEGISLADOR PARA EQUILÍBRIO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ENUNCIADO N. 21 DA I JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE DO CNJ. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À RELAÇÃO CONTRATUAL, SEMPRE VISANDO O EQUILÍBRIO. HARMONIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA E SEGUNDA SEÇÕES NO SENTIDO DE VELAR AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E A DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA AUTARQUIA ESPECIALIZADA. FIXAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE, EM REGRA, DA RELAÇÃO EDITADA PELA AGÊNCIA, COM ESTABELECIMENTO DE PARÂMETROS OBJETIVOS PARA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS SUBMETIDAS AO JUDICIÁRIO. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País. Já o art. 4º, III, elucida que compete à ANS elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades. 2. Por inequívoca opção do legislador, extrai-se tanto do art. 10, § 4º, da Lei n. 9.656/1998 quanto do art. 4º, III, da Lei n. 9.961/2000 que é atribuição dessa agência elaborar o Rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Nessa toada, o Enunciado n. 21 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ propugna que se considere, nos contratos celebrados ou adaptados na forma da Lei n. 9.656/1998, o Rol de procedimentos de cobertura obrigatória elencados nas resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ressalvadas as coberturas adicionais contratadas. 3. Por um lado, a Resolução Normativa ANS n. 439/2018, ora substituída pela Resolução Normativa ANS n. 470/2021, ambas dispondo sobre o rito processual de atualização do Rol, estabelece que as propostas de sua atualização serão recebidas e analisadas mediante critérios técnicos relevantes de peculiar complexidade, que exigem alto nível de informações, quais sejam, utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS, princípios da saúde baseada em evidências - SBE, manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. Por outro lado, deixando claro que não há o dever de fornecer todas e quaisquer coberturas vindicadas pelos usuários dos planos de saúde, ao encontro das mencionadas resoluções normativas da ANS, a Medida Provisória n. 1.067, de 2 de setembro de 2021, incluiu o art. 10-D, § 3º, I, II e III, na Lei 9.656/1998 para estabelecer, no mesmo diapasão do regramento infralegal, a instituição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10, devendo apresentar relatório que considerará: I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou a para a autorização de uso; II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar. 4. O Rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para assegurar direito à saúde, a preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável economicamente da população. Por conseguinte, considerar esse mesmo rol meramente exemplificativo - devendo, ademais, a cobertura mínima, paradoxalmente, não ter limitações definidas - tem o condão de efetivamente padronizar todos os planos e seguros de saúde e restringir a livre concorrência, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado, o que representaria, na verdade, suprimir a própria existência do "Rol mínimo" e, reflexamente, negar acesso à saúde suplementar à mais extensa faixa da população. 5. A par de o Rol da ANS ser harmônico com o CDC, a Segunda Seção já pacificou que "as normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei nº 9.656/1998. De qualquer maneira, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova" (EAREsp n. 988.070/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 8/11/2018, DJe de 14/11/2018). Dessa maneira, ciente de que o Rol da ANS é solução concebida pelo próprio legislador para harmonização da relação contratual buscada nas relações consumeristas, também não caberia a aplicação insulada do CDC, alheia às normas específicas inerentes à relação contratual. 6. Não se pode perder de vista que se está a discutir direitos e obrigações da relação contratual que envolvem plano de saúde e usuário, e não o estabelecimento de obrigação de fazer ou de não fazer a terceiro, que nem mesmo integra a lide. A ANS, ao contrário do médico-assistente da parte litigante, analisa os procedimentos e eventos sob perspectiva coletiva, tendo em mira a universalização do serviço, de modo a viabilizar o atendimento do maior número possível de usuários. Mesmo o correto e regular exercício profissional da Medicina, dentro das normas deontológicas da profissão, usualmente possibilita ao profissional uma certa margem de subjetividade, que, por vezes, envolve convicções pessoais ou melhor conveniência, mas não pode nortear a elaboração do Rol. 7. Conforme adverte a doutrina especializada, muito além de servir como arrimo para precificar os valores da cobertura básica e mínima obrigatória das contratações firmadas na vigência da lei de Planos de Saúde, o Rol de procedimentos, a cada nova edição, delineia também a relevante preocupação do Estado em não expor o consumidor e paciente a prescrições que não encontrem respaldo técnico estudado e assentado no mundo científico, evitando-se que virem reféns dos interesses - notadamente econômicos - da cadeia de fornecedores de produtos e serviços que englobam a assistência médico-hospitalar e odontológica suplementar. 8. Legítima é a confiança que está de acordo com o direito, despertada a partir de circunstâncias objetivas. Com efeito, o entendimento de que o Rol - ato estatal, com expressa previsão legal e imperatividade inerente, que vincula fornecedores e consumidores - deve ser considerado meramente exemplificativo em vista da vulnerabilidade do consumidor, isto é, lista aberta sem nenhum paralelo no mundo, ignora que é ato de direito administrativo, e não do fornecedor de serviços, assim como nega vigência a diversos dispositivos legais, ocasionando antisseleção, favorecimento da concentração de mercado e esvaziamento da competência atribuída à ANS pelo Poder Legislativo para adoção de medidas regulatórias voltadas a equilibrar o setor de saúde suplementar de forma ampla

e sistêmica, com prejuízo para toda a coletividade envolvida. Afeta igualmente a eficácia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF), pois a interferência no equilíbrio atuarial dos planos de saúde privados contribui de forma significativa para o encarecimento dos produtos oferecidos no mercado e para o incremento do reajuste da mensalidade no ano seguinte, dificultando o acesso de consumidores aos planos e seguros, bem como sua mantença neles, retirando-lhes a confiabilidade assegurada pelo Rol de procedimentos, no que tange à segurança dos procedimentos ali elencados, e ao Sistema Único de Saúde (SUS), que, com esse entendimento jurisprudencial, reflexamente teria sua demanda aumentada. 9. Em recentes precedentes específicos envolvendo a supressão das atribuições legais da ANS, as duas Turmas de Direito Público decidiram que, "segundo entendimento firmado neste Superior Tribunal de Justiça, até prova cabal em contrário, deve prevalecer a presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pelas agências reguladoras", "sendo inviável qualquer discussão acerca do próprio mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.266/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021). Ademais, assentaram que não é papel do Judiciário promover a substituição técnica por outra concepção defendida pelo julgador, sendo "incabível substituição da discricionariedade técnica pela discricionariedade judicial" (AgInt no REsp n. 1.823.636/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). 10. Diante desse cenário e buscando uma posição equilibrada e ponderada, conforme o entendimento atual da Quarta Turma, a cobertura de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no Rol da ANS somente pode ser admitida, de forma pontual, quando demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos, não bastando apenas a prescrição do médico ou odontólogo que acompanha o paciente, devendo ser observados, prioritariamente, os contidos no Rol de cobertura mínima. Deveras, como assentado pela Corte Especial na esfera de recurso repetitivo, REsp n. 1.124.552/RS, o melhor para a segurança jurídica consiste em não admitir que matérias técnicas sejam tratadas como se fossem exclusivamente de direito, resultando em deliberações arbitrárias ou divorciadas do exame probatório do caso concreto. Ressaltou-se nesse precedente que: a) não é possível a ilegítima invasão do magistrado em seara técnica à qual não é afeito; b) sem dirimir a questão técnica, uma ou outra conclusão dependerá unicamente do ponto de vista do julgador, manifestado quase que de forma ideológica, por vez às cegas e desprendido da prova dos autos; c) nenhuma das partes pode ficar ao alvedrio de valorações superficiais. 11. Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 12. No caso concreto, a parte autora da ação tem esquizofrenia paranoide e quadro depressivo severo e, como os tratamentos medicamentosos não surtiram efeito, vindica a estimulação magnética transcraniana - EMT, ainda não incluída no Rol da ANS. O Conselho Federal de Medicina - CFM, conforme a Resolução CFM n. 1.986/2012, reconhece a eficácia da técnica, com indicação para depressões uni e bipolar, alucinações auditivas, esquizofrenias, bem como para o planejamento de neurocirurgia, mantendo o caráter experimental para as demais indicações. Consoante notas técnicas de NatJus de diversos Estados e do DF, o procedimento, aprovado pelo FDA norte-americano, pode ser mesmo a solução imprescindível para o tratamento de pacientes que sofrem das enfermidades do recorrido e não responderam a tratamento com medicamentos - o que, no ponto, ficou incontroverso nos autos. 13. Com efeito, como o Rol não contempla tratamento devidamente regulamentado pelo CFM, de eficácia comprovada, que, no quadro clínico do usuário do plano de saúde e à luz do Rol da ANS, é realmente a única solução imprescindível ao tratamento de enfermidade prevista na Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, notadamente por não haver nas diretrizes da relação editada pela Autarquia circunstância clínica que permita essa cobertura, é forçoso o reconhecimento do estado de ilegalidade, com a excepcional imposição da cobertura vindicada, que não tem preço significativamente elevado. 14. Embargos de divergência a que se nega provimento. (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.)

Assim, nos termos do referido julgado, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses quanto à matéria *"in verbis":*

1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo;

2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;

3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;

4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Desta forma, tem-se que as coberturas de procedimentos médicos por planos de saúde se sujeitam a um rol mínimo editado pela ANS, o qual não pode prever as hipóteses do art. 10 da Lei nº 9.656/98 e não pode excluir ou mitigar as hipóteses do art. 12 da mesma Lei. Não obstante, evidentemente que os contratos firmados podem alargar o espectro mínimo de cobertura, inclusive cobrindo as hipóteses do citado art. 10.

Por conseguinte, entendo que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é tão somente referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde, não possuindo caráter taxativo, o que foi ratificado pela inclusão do § 12 no art. 10 da Lei nº 9.656/98 pela Lei nº 14.454/2022.

Todavia, cumpre destacar que o art. 10 da Lei 9.656/98 apresenta hipóteses expressas em que se possibilita a exclusão de cobertura pelas operadoras de plano de saúde, dentre as quais está incluído o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care, "in verbis"*:

Art. 10 - É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;

(...)

Art. 12 - São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

(...)

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

II - quando incluir internação hospitalar:

(...)

g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar.

Neste contexto, forçoso reconhecer que as operadoras de saúde, salvo contratação que amplie o âmbito de cobertura, não estão obrigadas à cobertura de medicamentos quando em uso domiciliar, à exceção dos antineoplásicos orais e medicações em regime de *home care* - hipóteses distintas da que se observa no caso em apreço.

Nada obstante, cabe referir que o dever de cobertura pela operadora do plano de saúde poderia exsurgir, ainda que se tratasse de medicamento de uso domiciliar não previsto no Rol da ANS, caso preenchidos os critérios dos incisos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, *"in verbis"*:

Art. 10 (...)

(...)

§ 13 - Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. ***(Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022)***

Por conseguinte, embora não se desconheça a patologia que acometia a parte autora (trombilifia), não verifico a presença dos requisitos elencados no § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, de modo a justificar o dever de cobertura pela operadora ré.

É que, em que pese o laudo médico prescreva o uso do fármaco ENOXOPARINA 40mg, por outro lado, não indica a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

A respeito, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO CONSTANTE DO ROL DA ANS. SEMAGLUTIDA (OZEMPIC). DE ACORDO COM A LEI Nº 14.454/22, EM CASO DE TRATAMENTO OU PROCEDIMENTO PRESCRITO POR MÉDICO QUE NÃO ESTEJA PREVISTO NO ROL DA ANS, A COBERTURA DEVERÁ SER AUTORIZADA PELA OPERADORA DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, DESDE QUE EXISTA COMPROVAÇÃO DA EFICÁCIA, À LUZ DAS CIÊNCIAS DA SAÚDE, BASEADA EM EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS E PLANO TERAPÊUTICO. OS ELEMENTOS APRESENTADOS NÃO PERMITEM O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. PARA TAL, DEVEM ESTAR PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORRE NO CASO ORA EXAMINADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51900415720228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 15-12-2022).

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE TROMBOFILIA GESTACIONAL. MEDICAMENTO DENOMINADO ENOXAPARINA. COBERTURA INDEVIDA. RETORNO DO STJ. NOVO JULGAMENTO. 1. OS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO SUBMETIDOS ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, RAZÃO PELA QUAL SE APLICA O DISPOSTO NO ART. 35 DA LEI 9.656/98 AO CASO EM TELA, DECORRENTE DE INTERPRETAÇÃO LITERAL E MAIS BENÉFICA AOS ADERENTES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 608 DO STJ. 2. NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ, NÃO SE AFIGURA ILÍCITA A EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, SALVO OS ANTINEOPLÁSICOS ORAIS (E CORRELACIONADOS), A MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) E OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. 3. HIPÓTESE EM QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, A JUSTIFICAR A MITIGAÇÃO DA EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50000826920198210114, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-03-2023).

Destarte, tenho que a improcedência da ação é medida que se impõe, cumprindo, pois, revogar a tutela de urgência concedida no documento 1 do evento 4.

Isto posto, **JULGO IMPROCEDENTE** a presente **Ação de Obrigação de Fazer** ajuizada por **Sara Steinmetz Moreira de Azevedo** contra **Bradesco Saúde S/A**, partes já qualificadas, forte no art. 485, VI, do CPC, revogando a tutela de urgência concedida no documento 1 do evento 4.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios dos procuradores da parte adversa, os quais fixo em R$ 1.500,00, corrigidos, pelo IGP-M, desde a data da publicação da sentença, até o efetivo pagamento, forte no art. 85, § 8º, do CPC, ficando a mesma dispensada de tais ônus, eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA ROSA MOROZINI, Juíza de Direito**, em 28/9/2023, às 18:20:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10046743264v23** e o código CRC **b304e09d**.